

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9797/2560

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

เด็กหญิง พ. โดยนางสาว ส.

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้ร้อง

นายจักรีหรือยอด นาคสนั่น

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง

ป.พ.พ. มาตรา 420

ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายยังเป็นเด็กอายุ 13 ปีเศษ และพยานหลักฐานโจทก์  
ฟังได้ว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอม ที่จำเลยฎีกาในคดีส่วน  
แพ่งว่า เมื่อผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา จึงไม่เป็นละเมิด จำเลยไม่ต้อง  
รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายนั้น ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  
"ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น  
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษ..." แสดงว่า กฎหมายคุ้มครองเด็กอายุน้อย  
เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ให้ความสำคัญแก่ความยินยอมของเด็ก ดังนั้น แม้ผู้เสียหาย  
ยินยอม การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ผู้เสียหายมี  
สิทธิเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจำเลย และมารดาผู้เสียหายย่อมมีสิทธิยื่นคำร้อง  
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยแทนผู้เสียหายได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 364 และ 365

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา เด็กหญิง พ. ผู้เสียหายโดยนางสาว ส. มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ 200,000 บาท ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล 200,000 บาท และค่าทนายชั้ประมาณ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

### จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, (ที่ถูก มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม)), 365 (3) ประกอบมาตรา 364 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี และให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 16 มกราคม 2558) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีส่วนแพ่งให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 16 มกราคม 2558) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้

ร้อง โทษและนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมคดีส่วนแพ่งชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสียหายเกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 เป็นบุตรของนางสาว ส. กับนาย ธ. ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุ 13 ปีเศษ และพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่บ้านเกิดเหตุ ส่วนจำเลยพักอาศัยอยู่กับนางสาว จ. ที่บ้านเช่าของญาตินางสาว ส. อยู่ติดกับบ้านเกิดเหตุ วันที่ 24 เมษายน 2557 นางสาว ส. ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาจำเลยเป็นคดีนี้ สำหรับความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์และผู้ร้องมิได้ฎีกา คดีเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายเคยพูดคุยกับจำเลยผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก จำเลยใช้ชื่อว่า JUGKREE ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยปีนจากระเบียงบ้านชั้นบนเข้ามาในห้องนอน จำเลยผลักผู้เสียหายล้มลงบนเตียงนอน แล้วถอดกางเกงยืดยาวของผู้เสียหายออก จากนั้นจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายพยายามผลักจำเลยออกแต่สู้แรงจำเลยไม่ได้ ต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีน้ำเลอะที่บริเวณขา คาดว่าจำเลยไม่ได้หลั่งน้ำอสุจิภายในช่องคลอด จำเลยสวมกางเกงและออกไปทางประตูระเบียง ผู้เสียหายอาบน้ำทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ โดยไม่ได้เล่าให้ผู้ใดฟัง หลังเกิดเหตุจำเลยกล่าวขอโทษผู้เสียหายผ่านทางเฟซบุ๊กถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ต่อมาในวันที่ 24 เมษายน

2557 ผู้เสียหายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟซบุ๊กและโทรศัพท์ให้นาย ค. นักเรียนรุ่นพี่ทราบ นาย ค. แจ้งให้มารดานาย ค. ทราบ ต่อมานางสาว ส. ทราบเรื่องจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ผู้เสียหายถูกส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ และนาย ค. พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ผู้เสียหายส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงพยานในทำนองว่าผู้เสียหายเป็นคนไม่ดี ไม่อยากติดต่อกับพยานอีก โดยผู้เสียหายส่งข้อความสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยให้พยานดูด้วย มีข้อความว่า ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับจำเลย พยานโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พยานฟัง พยานไปบอกนาง น. มารดาพยาน นาง น. โทรศัพท์แจ้งให้มารดาผู้เสียหายทราบ กับโจทก์มีนางสาว ส. เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อพยานทราบเรื่องจากนาง น. แล้ว พยานสอบถามผู้เสียหายในวันนั้น ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกจำเลยคนข้างบ้านข่มขืน พยานไปหาจำเลยที่บ้านแล้ว จำเลยบอกว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหาย พยานให้จำเลยโทรศัพท์ไปหามารดาจำเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำเลยจึงคุกเข่าลงและยอมรับว่าทำจริง พยานขอบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยและไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน โดยมอบบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยให้แก่พนักงานสอบสวนด้วย นอกจากนี้โจทก์มีพนักตำรวจโทหญิง ต. พนักงานสอบสวน เป็นพยานเบิกความว่า หลังจากรับแจ้งเหตุแล้ว พยานส่งตัวผู้เสียหายให้แพทย์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ วันรุ่งขึ้นได้แจ้งข้อกล่าวหาจำเลย จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาพยานได้รับแจ้งผลการตรวจชันสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้ว ส่วนจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความอ้างฐานที่อยู่ว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยนั่งเล่นเกมที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพัก จำเลยไม่เคยปีนระเบียงเข้าไปในบ้านพักของผู้เสียหายและมิได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยรู้จักผู้เสียหายผ่านทางเฟซบุ๊ก แต่ข้อความตามสำเนาภาพถ่ายไม่มีข้อความระบุว่า จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย เห็นว่า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายยังเป็นเด็กอายุ 13 ปีเศษ กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่เคย

มีเพศสัมพันธ์หรือเคยมีสาเหตุโรคเรื้อรังจำเลยมาก่อน ประกอบกับได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน ผู้เสียหายเคยติดต่อสัมพันธ์กับจำเลยที่ใช้ชื่อว่า JUGREE ในสื่อสังคมออนไลน์หรือเฟซบุ๊ก ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธว่า ข้อบัญญัติผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวมิใช่ของจำเลย ทั้งหากเรื่องที่ผู้เสียหายถูกจำเลยกระทำชำเราไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายคงไม่กล้าที่จะส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไปให้นาย ค. เพื่อนนักเรียนรุ่นพี่ว่าผู้เสียหายเป็นคนไม่ดี ไม่อยากติดต่อกับนาย ค. อีก และยังส่งข้อความที่ผู้เสียหายสนทนาทางเฟซบุ๊กกับผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับจำเลย เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอับอายขายหน้า เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของผู้เสียหายเอง ซึ่งนาย ค. ก็เบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายส่งข้อความดังกล่าวทางเฟซบุ๊กจริง นาย ค. จึงแจ้งเรื่องให้นางนิภารัตน์ มารดานาย ค. ทราบ อันเป็นเหตุให้นาง น. แจ้งให้นางสาว ส. มารดาผู้เสียหายทราบ และไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลย แม้ข้อความสนทนาระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย จะไม่มีข้อความโดยชัดแจ้งว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายดังที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาก็ตาม แต่ก็มีข้อความทำนองผู้เสียหายพูดคุยกับจำเลยในลักษณะตัดพ้อต่อว่าเกี่ยวกับการที่จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายในเชิงขู่สาว่า จำเลยตอบผู้เสียหายทำนองว่าจำเลยมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายเนื่องด้วยความรักในตัวผู้เสียหายมิใช่ความใคร่ จำเลยยอมให้มารดาผู้เสียหายแจ้งตำรวจจับจำเลยก็ได้ จำเลยยอมหมดแล้ว นอกจากนี้ยังได้ความว่า เมื่อนางสาว ส. เรียกจำเลยมาสอบถาม ในครั้งแรกจำเลยปฏิเสธ เมื่อนางสาว ส. ให้จำเลยโทรศัพท์ไปหามารดาจำเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำเลยจึงคุกเข่าลงและยอมรับว่าทำจริง และมอบบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยให้แก่นางสาว ส. ยิ่งสนับสนุนให้เชื่อว่าหากจำเลยมิได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริงแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะต้องยอมรับผิดและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางสาว ส. อันเป็นการผูกพันตนเองเช่นนี้ แม้ผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายจะไม่พบตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิ ไม่พบบาดแผลใหม่บริเวณอวัยวะเพศ ไม่พบหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ

ภายใน 7 วัน ดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่ผู้เสียหายเบิกความว่า ผู้เสียหายรู้สึกมีน้ำ  
เลอะที่บริเวณขา คาดว่าจำเลยไม่ได้หลังน้ำอสุจิภายในช่องคลอด และหลังจากมีเพศ  
สัมพันธ์กับจำเลยแล้ว ผู้เสียหายเข้าไปอาบน้ำโดยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ  
มากกว่าปกติ จึงอาจเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถตรวจพบน้ำอสุจิหรือส่วนประกอบของ  
น้ำอสุจิ ทั้ง พลตำรวจตรี พ. แพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายเบิกความว่า ตามปกติ  
การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลที่อวัยวะเพศ กรณีจึงเป็นไปได้ว่าจำเลยกระทำ  
ชำเราผู้เสียหายในลักษณะละมุนละม่อมโดยสมัครใจยินยอมของผู้เสียหาย มิได้  
กระทำในลักษณะข่มขืนหรือกระทำอย่างรุนแรง จึงไม่ปรากฏบาดแผลที่อวัยวะเพศ  
ของผู้เสียหายดังที่พลตำรวจตรี พ. พยานโจทก์เบิกความ ที่จำเลยฎีกาอ้างฐานที่อยู่  
ว่า คืบเกิดเหตุจำเลยนั่งเล่นเกมอยู่กับนาย ก. และนาย ท. จำเลยไม่ได้เข้าไปในห้อง  
ของนางสาว จ. เพื่อผ่านไปห้องนอนผู้เสียหายซึ่งมีระเบียบชั้นบนติดต่อกัน หลังเกิด  
เหตุจำเลยไม่ได้ยอมรับต่อนางสาว ส. ว่า จำเลยทำผิดจริงและมีได้มอบบัตรประจำ  
ตัวประชาชนของจำเลยให้แก่นางสาว ส. แม้จำเลยจะมีนาย ก. นางสาว จ. และ  
นางสาว ด. มาเบิกความเป็นพยาน แต่นาย ก. เป็นคนรู้จักกันกับจำเลย นางสาว จ.  
และนางสาว ด. เป็นญาติจำเลย จึงอาจเบิกความช่วยเหลือเข้าข้างจำเลยก็เป็นได้ จึง  
ไม่น่ารับฟังและไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ทั้งพันตำรวจโทหญิง ต.  
พนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่า นางสาว ส. มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี  
แก่จำเลยพร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยตรงตามที่นางสาว ส. เบิก  
ความ ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหาย  
ยินยอมดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย  
ฎีกาในปัญหาข้ออื่นของจำเลยอีกเพราะไม่มีผลทำให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป

สำหรับที่จำเลยฎีกาในคดีส่วนแพ่งว่า เมื่อผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกระทำ  
ชำเรา จึงไม่เป็นการกระทำโดยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
420 จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายนั้น เห็นว่า ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุ  
ยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
ต้องระวางโทษ..." แสดงว่า กฎหมายคุ้มครองเด็กอายุน้อยเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ให้  
ความสำคัญแก่ความยินยอมของเด็ก ดังนั้น แม้ผู้เสียหายยินยอม การกระทำของ  
จำเลยก็ยังเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ มาตรา 420 ผู้เสียหายจึงไม่สิ้นสิทธิในการเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจาก  
จำเลย นางสาว ส. ในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายย่อมมีสิทธิยื่น  
คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยแทนผู้เสียหายได้ ทั้งค่าสินไหมทดแทนที่  
ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำนวน 200,000 บาท นั้น ก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ศาลฎีกา  
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประมวล รักษศีลธรรม-วิริยภัย สายสมบัติ-ชลิต กฐินะสมิต)

ศาลอาญา - นายพลัส เทอดไทย

ศาลอุทธรณ์ - นายชวิน อยู่เปนสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ421/2559

ต้น

หมายเหตุ